

1500793-30.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... a desclassificação do crime de tráfico para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (fls. 329/346).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06).

De início, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500793-30.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500793-30.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142773/2022 - DEL.POL.BIRIGUI, 25189744 -

DEL.POL.BIRIGUI, 2142773 - DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR CEZAR GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1500793-30.2022.8.26.0603 (Controle nº 1213/2022)

VISTOS.

JUNIOR CEZAR GONÇALVES, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 13h30, na Rua Filomena Cristóvão de Carlis, 686, nesta cidade e comarca de Birigui, trazia consigo 196,03 (cento e noventa e seis gramas e três centigramas) de maconha, fracionados em 02 porções; 15,45 (quinze gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína acondicionados em 02 sacos tipo "zip lock" e 17,33 (dezessete gramas e trinta e três centigramas) de cocaína acondicionados em 01 porção, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de constatação prévia de fls. 22/30 e laudo de exame toxicológico de fls. 158/166.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 287), cuja peça foi juntada às fls. 211/229, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 25 de julho de 2022 (fls. 241/243) e a citação do acusado à fl. 303.

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas em comum e 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 315/316).

Em alegações, o Ministério Público pleiteou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 323/326).

A defesa, por sua vez, em preliminar, alegou nulidade da prova obtida por meio ilícito. No mérito, pediu a absolvição do réu, em razão de não haver provas suficientes para a condenação. Por fim, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (fls. 329/346).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

De início, a matéria arguida pela defesa, quanto à busca domiciliar na casa do acusado sem mandado judicial, fica rejeitada.

Pelo que se relatou, os policiais militares foram cumprir um mandado de prisão e avistaram o acusado arremessando uma sacola no telhado vizinho e foi franqueada a entrada na residência pelo acusado. Na sacola continha 196,03 (cento e noventa e seis gramas e três centigramas) de maconha, 15,45 (quinze gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína e 17,33 (dezessete gramas e trinta e três centigramas) de crack.

Logo, evidente que houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam.

Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, no caso de flagrante delito, como foi o ora tratado.

Como se não bastasse, é cediço que, em se tratando de crime permanente, é dispensável qualquer exibição de mandado e também a presença de civis no local, até porque se sabe que, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo, tudo por receio de represálias e ameaças por parte dos traficantes. Desprezar, como regra, a ação dos policiais em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.

Por fim, anoto que a matéria foi recentemente objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cassou a decisão proferida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas razões adoto, aqui, como razão de decidir, para afastamento dessa preliminar:

"De acordo com sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o

tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial ou congêneres, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na formodo disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A propósito: “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui delito permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente.” (Superior Tribunal de Justiça, HC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª Câmara – Seção Criminal Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439 - Pereira Barreto 5 451502/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). Em função disso, sempre que houver fundada suspeita da ocorrência do referido ilícito penal, não será possível falar em ilegalidade na ação dos agentes públicos, nem em ilicitude da prova amealhada, por inexistência de mandado de busca prévio ou específico, ou por estar caracterizada a invasão domiciliar. Afirmar-se o contrário implicaria prestigiar a atividade criminosa, em detrimento do trabalho policial realizado por agentes

públicos regularmente investidos em suas funções, que ficariam inviabilizadas, com prejuízo irreparável para a sociedade. Imagine-se, por exemplo, que policiais estivessem realizando ronda rotineira, no exercício do policiamento preventivo e, ao passarem diante de uma residência qualquer, ouvissem gritos de socorro de uma mulher. A prevalecer o raciocínio segundo o qual o ingresso em residência só pode ocorrer quando houver segura conclusão acerca de crime em seu interior, mesmo diante da suspeitada ocorrência de violência doméstica, os agentes públicos estariam impossibilitados de intervir, e só poderiam ingressar na residência após a obtenção de ordem judicial, ou se a tanto autorizados pelo possível agressor, ou seja, quando o socorro à vítima já não seria mais útil. Tão absurda situação equivaleria à concessão de um passe livre para que residências servissem de palco para a prática dos mais diversos e graves delitos (homicídios, sequestros, lesões corporais, tráfico, estupro de vulneráveis, etc.), colocando a proteção às vítimas e da sociedade em patamar inferior aos direitos dos criminosos, e privilegiando a impunidade)... E nem se diga, por outro lado, que a diligência policial não foi devidamente documentada. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se exigia documentação e registro audiovisual para o ingresso de policiais em residências (Habeas Corpus nº 598051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.342.077-SP, de que foi relator o Ministro Alexandre de Moraes, realizado no dia 02 de dezembro de 2021, ficando assentado que é “Incabível, portanto, na presente hipótese, em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias, para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE”. Enfim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, nem é o caso de se determinar o desentranhamento de qualquer elemento probatório dos autos, já que todas as provas produzidas se afiguram válidas. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439, Comarca de Pereira Barreto, 11ª Câmara de Direito Criminal, V.U., j. 03/02/22, rel. Des. XAVIER DE SOUZA).

No mérito, ação penal é procedente, respeitado o entendimento exposto pela acusação e defesa em suas alegações finais.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01); o boletim de ocorrência (fls. 08/11); a nota de culpa (fl. 06); o relatório final (fls.

167/169); os laudos de constatação prévia (fls. 22/30); os laudos periciais (fls. 158/166); os depoimentos das testemunhas; e as indigestas negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Na delegacia, o acusado negou a traficância, disse que, quando os policiais chegaram, estava descansando dentro da residência com seu amigo Alexandre. Não possuía nenhuma porção de droga no local e não dispensou sacola com droga no telhado vizinho. Disse que os policiais "apareceram" com a sacola com entorpecentes. Negou que as drogas lhe pertenciam (fl. 05).

Em juízo, alterou sua versão, disse que a droga lhe pertencia, alegando que seria para consumo próprio. Disse que ao avistar os policiais arremessou a sacola com a droga no telhado vizinho. Afirmou não ter sido ouvido na delegacia, que só assinou os papéis que lhe foram apresentados. Disse que não tinha ciência do mandado de prisão e alegou ser usuário, sendo seu vício sustentado por sua mãe (fls. 315/316). Como se vê, há contradições nos interrogatórios do acusado, pois em primeiro momento, na delegacia, negou que os entorpecentes lhe pertenciam. Em juízo, assumiu a propriedade, porém, alegou ser para consumo próprio.

Diante dessas contradições, relacionadas a pontos de fundamental relevância para o deslinde da causa, não há como se dar credibilidade às versões apresentadas pelo acusado, que restaram contraditórias e isoladas, se cotejadas às demais provas coligidas sob o crivo do contraditório, que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, como se verá doravante, tratando-se de mero expediente utilizado na tentativa de afastar a responsabilização penal por conduta efetivamente praticada. Não prospera a afirmação do acusado de que teria assinado seu interrogatório na delegacia sem ler, porque prestou declarações perante a Autoridade Policial que presidiu a elaboração do flagrante, como se observa do documento de fl. 155. Ademais, o acusado, naquela ocasião, não relatou qualquer pressão para que assim o fizesse.

Os demais elementos de prova colhidos na instrução comprovaram a imputada dirigida ao acusado na denúncia.

Com efeito, as testemunhas Wellington Rodrigo Doná e Eder Luiz de Mattos, policiais militares, ouvidas em ambas as fases da persecução penal, disseram que sabiam da existência do mandado de prisão em desfavor de Junior, e que avistaram um indivíduo saindo da residência do acusado, que afirmou que Junior se encontrava no local. Assim, solicitaram apoio e cercaram o imóvel. Com o auxílio de uma escada, visualizaram o acusado arremessando uma sacola no telhado da residência vizinha. O acusado franqueou a entrada dos policiais e foi informado do mandado de prisão. Na sacola dispensada pelo acusado havia porções de maconha, cocaína e crack. O policial Wellington afirmou que já haviam denúncias de que o imóvel era ponto de tráfico de drogas. Na residência estava também o indivíduo identificado como Alexandre (fls. 02, 03 e 315/316).

Como se vê, os policiais confirmaram que encontraram considerável quantidade de entorpecentes na residência do acusado, confirmando as denúncias de que ali se traficava.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terão valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

A testemunha de defesa, Elaine Gonçalves, ouvida na fase judicial, irmã do acusado, disse que não mora com o acusado e ficou sabendo que os policiais estavam lá e foi verificar. Afirmou que seu irmão é usuário de entorpecentes. Disse que o acusado estava desempregado e que sua mãe sustentava o vício dele. Acompanhou a revista na residência onde nada foi localizado e os policiais lhe apresentaram a sacola que

foi arremessada na residência vizinha, e pediram para falar pra seu irmão assumir a propriedade da droga (fls. 315/316).

A testemunha Alexandre Luiz Silva Batista, ouvida na delegacia, disse ser amigo do acusado e que foi na residência do acusado para lavar uma motocicleta. Afirmou que levou um cigarro de maconha e consumiu junto com o acusado, sendo a única droga que viu naquela casa. Disse que o acusado trabalha como caminhoneiro e não "mexe" com drogas. Não viu o acusado com sacola de droga nenhuma e nada sabe sobre estes fatos (fl. 04).

Essa testemunha, apesar de ouvida na delegacia, não foi trazida em juízo pelo acusado, para confirmar sua versão, razão pela qual seu depoimento não prevalece sobre o dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, a testemunha de nome Jonathan não foi ouvida, prevalecendo, mais uma vez, os depoimentos dos policiais.

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consiste realmente em "maconha" e "cocaína" (exame químico-toxicológico de fls. 158/166).

De outra parte, a quantidade de entorpecentes apreendidos, ou seja, 196,03 (cento e noventa e seis gramas e três centigramas) de maconha, 15,45 (quinze gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína e 17,33 (dezesete gramas e trinta e três centigramas) de crack, as circunstâncias da abordagem do réu (cumprimento de mando de prisão e denúncias de que o local era ponto de tráfico); apreensão de celular e sacos plásticos zip lock; estão a caracterizar a traficância.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado por trazer consigo entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado trazia consigo 196,03 (cento e noventa e seis gramas e três centigramas) de maconha; 15,45 (quinze gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína e 17,33 (dezesete gramas e trinta e três centigramas) de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, respeitado o entendimento exposto pela acusação e pela defesa, embora o acusado, em seu interrogatório, tenha alegado que é usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental. Ademais, em seu interrogatório, o réu mostrou-se lúcido.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra conduta. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Para a rejeição da pretendida desclassificação, este Juízo está aplicando exatamente o artigo de lei (art. 28, § 2º, da LD), ou seja, está levando em conta, as condições em que se desenvolveu a ação (repita-se: havia denúncia de tráfico de drogas no local; apreensão de sacos plásticos zip lock; o réu, inicialmente, negou a propriedade dos entorpecentes, dizendo que os policiais “apareceram” com as drogas e, depois, passou a dizer que a droga era para seu consumo; a quantidade dos entorpecentes apreendidos demonstram a ocorrência da traficância).

Assim, descabida a desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei de Drogas.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado ostenta mau antecedente (fls. 348/349 – processo nº 0010342-87.2010.8.26.0077), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe é favorável, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Afora isso, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 196,03 gramas de maconha; 15,45 gramas de cocaína e 17,33 gramas de crack), se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repressão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154).

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, nos aspectos acima relatados (mau antecedente e quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fl. 349 - Proc. nº 0010674-10.2017.8.26.0077), assim, elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a ser consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que afasta o benefício.

Ademais, ainda que assim não fosse, restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de drogas, de espécies diversas, que o acusado se dedicava à narcotraficância em escala expressiva, guardando grande quantidade de droga, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Neste sentido, já se decidiu:

“ Sem incidência , porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida - para fim de venda a indeterminado número de pessoas - antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa.”

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz jus à redução em questão.

Torno definitiva a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do

artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 26/05/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.



Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem todos os argumentos expostos nos votos supracitados, no caso concreto, a substituição não é possível, porque a pena aplicada é superior a quatro anos e o réu é reincidente em crime doloso e ostenta mau antecedente, não preenchendo, pois, os requisitos legais para a substituição. Afora isso, o réu guardava considerável quantidade de entorpecente para entrega a consumo de terceiros, o que demonstra que o benefício não seria recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime praticado.

O acusado deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão preventiva foi decretada às fls. 76/80, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir, bem como aqueles expostos na decisão de fls. 232/233, que indeferiu

pedido de liberdade provisória.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos. Afora isso, o acusado estava foragido por outro processo. Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo.

Por fim, anote-se que o réu guardava grande quantidade de droga, o que traria efeitos altamente lesivos à sociedade e só vem confirmar a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, para garantia da ordem pública, lembrando que o acusado ostenta mau antecedente é reincidente em crime doloso.

A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do acusado, estão as decisões proferidas no Habeas Corpus impetrado em favor do acusado, que teve sua liminar indeferida (fls. 266/269).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada e realizada (fl. 317), nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Quanto aos sacos plásticos zip lock apreendidos (fls. 14/15), embora sejam instrumentos do tráfico de drogas, o certo é que, diante da natureza do objeto, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Em relação ao celular apreendido às fls. 14/15, diante da natureza do objeto, (e por serem, os celulares, instrumentos para a prática do tráfico de drogas), entendo não ser caso de perda para o SENAD, mas sim destruição, a qual fica desde já determinada, mas que deverá ser cumprida somente após o trânsito em julgado da presente.

Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre a destruição dos objetos.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA